

1513923-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513923-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513923-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN DA SOLEDADE PEREIRA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

KAUAN DA SOLEDADE PEREIRA VIEIRA foi denunciado e se vê processado pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329, caput, do Código Penal, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", e na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque, (i) no dia 14 de junho de 2022, por volta das 16h16min., durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), na Rua Valdomiro dos Santos Pereira, nº 160, Conjunto Habitacional, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 209 (duzentos e nove) invólucros de plástico, pesando 400g (quatrocentos gramas) contendo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e (ii) nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima, se opôs à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os Policiais Civis Fabiano Santos Gonçalves e William Fraga Volpi, causando em Fabiano as lesões corporais de natureza leve.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 12.

Laudo de Constatação, a fls. 14/16.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 129/131.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12, Laudo de Constatação de fls. 14/16 e Laudo Pericial de fls. 129/131, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha.

Já a materialidade do crime contra a Administração encontra respaldo no exame de corpo de delito acostado a fls. 152/153.

A autoria dos crimes imputados ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente, bem como o ato de resistência, mediante violência empregada contra os oficiais da lei.

Interrogado na fase policial, o acionado negou a prática dos crimes, afirmando que "no momento da abordagem policial, havia recém chegado no local onde são vendidas drogas, uma vez que pretendia comprar um "baseado". Na ocasião, o ROBERTO, responsável por vender maconha no local, pediu para que segurasse a pochete que continham as drogas, dizendo que iria resolver um problema de forma rápida, mas que já voltaria. Acrescenta que, no local, há também a pessoa de LUAN que é responsável pela venda do pó. Indagado, assevera que o dono da biqueira se trata de uma pessoa conhecida por "DÉ", o qual é conhecido por todos por ostentar esta posição. Pontua, ainda, que ROBERTO levou, inclusive, o dinheiro que recebem com a venda das drogas. Defende que não estava vendendo nenhum entorpecente. Indagado, diz que tem conhecimento que os traficantes buscam a droga no campo do "Sabão" (onde tem uns prédios). Por fim, conta que o outro indivíduo que estava no local se trata de LUCAS (pessoa de cor negra e de estatura alta), que, por sua vez, tem a função de ficar trancando e abrindo o portão do conjunto habitacional." (fls. 20/21).

Nesta audiência, com algum rodeio, confessou a prática do tráfico de drogas.

Doutro lado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria.

Ouvidos em Juízo, as testemunhas policiais civis, responsáveis pela prisão do acionado, Fabiano Santos Gonçalves e William Fraga Volpi, relataram, em absoluta harmonia, que estavam realizando investigações, no âmbito da denominada "Operação Sufoco", com a finalidade de prevenir e reprimir o cometimento de crimes na região, quando, após efetuarem uma campana em uma das entradas do conjunto habitacional denominado de "50", localidade notoriamente conhecida no bairro pela prática do crime de tráfico de drogas, observaram quatro jovens que estabeleciam, repetidamente, contato verbal com outras pessoas que deles se aproximavam, ocasião em que passavam a adotar comportamento característico da comercialização de entorpecentes. Isso porque, após receberem o que parecia se tratar de dinheiro, entregavam para aquelas pessoas algo que traziam no interior das pochetes que portavam. Em virtude da situação absolutamente suspeita, típica da comercialização de drogas, decidiram por realizar a abordagem do grupo. Assim, se dividiram, o policial Fabiano entrou no condomínio pela parte de trás. Contudo, ao emitir o comando da parada, porém, identificando-se como policial, os indivíduos iniciaram fuga do local, correndo para o interior do conjunto habitacional. Neste contexto, Fabiano conseguiu segurar um dos quatro indivíduos pelo braço, posteriormente identificado como sendo o acionado, o qual, por sua vez, opondo-se à abordagem, usou de força física contra o policial Fabiano, pretendendo se desvencilhar da prisão, mantendo forte resistência para não ser abordado, o que fez com que o policial Fabiano caísse ao solo, o que lhe causou contusão e escoriações no dorso da mão esquerda e joelho da perna direita. No entanto, em que pese a violência empregada, conseguiu deter KAUAN, agarrando-o com a chegada do seu colega, o policial civil William, que o ajudou na realização da captura. Algemado o suspeito, procederam à busca pessoal, ocasião em que encontraram no interior da pochete que KAUAN portava considerável quantidade de porções individualmente embaladas de erva esverdeada similar a maconha, denotando que se encontravam preparadas para a comercialização. Os demais indivíduos, contudo, conseguiram se evadir do local.

Diante das circunstâncias efetuaram a detenção e condução de KAUAN até a presença da autoridade policial para a tomada das medidas de polícia judiciária. Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo drogas, consistentes em 209 (duzentos e nove) invólucros plásticos, contendo 400g (quatrocentos gramas) da substância Tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 209 (duzentas e nove) unidades, o modo de acondicionamento, subdivididas em porções individuais, as circunstâncias do flagrante, tendo o acionado tentado fugir da abordagem policial e, pior, a ela resistido violentamente, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem sido flagrados executando atos de mercancia não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tráfico. Afinal, tratando-se de crime cometido em situação de clandestinidade, nem sempre é possível evidenciar a execução efetiva de atos de venda. No mais, sendo o tráfico crime de ação múltipla, configura-se a figura delitiva com a prática de um dos verbos núcleo do tipo penal elencado pelo art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a flagrância de práticas comerciais. Ou seja, o próprio porte e a guarda de substâncias podem subsumir-se àquela figura delituosa, desde que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação (Apelação Criminal nº 0000029-81.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de março de 2020, rel. Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Prosseguindo, entendo que o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, igualmente se comprovou.

A materialidade de tal delito encontra lastro no exame de corpo de delito de fls. 152/153, que bem demonstra as lesões corporais sofridas pelo policial Fabiano. A autoria decorre da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Vale registrar que as declarações dos policiais devem ser tomadas como as de quaisquer outras testemunhas.

Neste sentido, é firme a jurisprudência:

"A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, 'o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello)".

Ou seja, no visio de não ser preso e identificado, resistiu ao ato legal de prisão. Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, do Código Penal, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao agente, mormente considerando que de seu comportamento violento quando da abordagem restou configurada infração autônoma.

Contudo, considerando a elevada quantidade de entorpecentes localizados com KAUAN (209 porções, com o total de 400g), fixo suas penas-base para o crime de tráfico de drogas em patamar 1/6 acima do mínimo, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Já para o crime de resistência, fixo a pena em dois meses de detenção.

Em segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica decorrente da menoridade relativa do acusado, que, à época dos fatos, contava com apenas 18 anos de idade. Ainda, relativamente ao delito de tráfico, presente, também, a atenuante da confissão.

Assim, torno as penas aplicadas pelo crime de tráfico ao patamar mínimo previsto em lei.

Com relação ao crime previsto no art. 329, caput, do CP, as penas do acusado permanecem no mínimo legal, nos termos da súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Revedo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.

De toda forma, considerando a boa quantidade de droga localizada em sua posse, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Concluo, finalmente, pelo concurso material de infrações, nos termos do art. 69, caput, do CP.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Malgrado em situação parelha, relativamente ao delito de tráfico, diante do meu entendimento pessoal, o regime mais gravoso seja o mais adequado, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto.

Adira-se, neste ponto, ainda, a determinação contida no julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, in verbis:

Dispositivo. À vista de todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para: 1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. 3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior - determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Tal regime mais benéfico, inclusive, se estende ao delito remanescente, à mingua da necessidade de maior censura.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu KAUAN DA SOLEDADE PEREIRA VIEIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 02 (dois) meses de detenção, ambas as penas corporais no regime inicial aberto, além do pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº

11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, e, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa,

no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.
Por conta da pena mensurada, defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.
Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, mantida, neste ponto, a decisão de fls. 143, in fine.
Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06